

<입문-제1장 개설.제4절 행정법의 법원>

I. 개설

1. 의의

- 행정법의 법원(法源)이란 행정주체의 행정작용에 대한 구속력을 가지는 법규범의 존재 형식을 의미한다. 이는 행정조직, 행정작용, 행정 구제 등 행정법 관계를 규율하는 법의 연원(淵源)으로서, 재판 기관(법원)이 행정소송을 통해 행정작용의 위법성을 판단할 때 판단 근거가 되는 규범들을 포괄한다. 법치 행정의 원리상 행정은 법원에 의해 구속되며, 행정주체가 법원을 위반한 행정작용을 한 경우 위법성이 인정된다.

2. 학설

(1) 실질적 의미의 법원

- 실질적 의미의 법원은 내용 면에서 행정법 관계를 규율하는 모든 규범을 의미한다. 이는 성문 법규범(헌법, 법률 등)뿐만 아니라 불문 법규범(관습법, 조리)까지 포함하는 가장 광의의 개념이다. 재판 기관이 행정의 위법성을 판단할 때 실제로 적용하는 모든 규범을 포괄한다.

(2) 형식적 의미의 법원

- 형식적 의미의 법원은 법의 존재 형식을 기준으로 성문(成文)의 형태로 존재하는 규범만을 의미한다. 이는 법전 또는 공식적인 문서로 작성되어 명시적인 효력을 가지는 규범으로서, 주로 국내법인 헌법, 법률, 명령 등을 지칭한다.

(3) 법적 확신설

- 법적 확신설은 행정법의 법원이 되기 위해서는 국가 또는 구성원의 일반적인 법적 확신을 얻고 있어야 한다는 견해이다. 이는 관습법과 같은 불문 법원의 법적 효력 근거를 설명하는 데 유용하다.

3. 특징

(1) 다양성과 복잡성

- 행정법은 공익 실현이라는 다양한 목적을 추구하므로, 그 법원 역시 헌법, 법률 등 상위 법규범뿐만 아니라 국제법, 지방자치단체 조례·규칙 등 다양한 영역에서 발생하며 그 체계가 복잡하다. 특히, 행정관습법과 조리와 같은 불문 법원이 중요한 역할을 수행한다.

(2) 성문법원 중심주의

- 법치 행정의 원리와 국민의 권리 보호의 명확성 때문에, 행정법은 법률이라는 성문 법원을 중심으로 구성되며, 불문 법원은 성문법의 결함을 보충하거나 해석의 기준을 제시하는 보충적 역할에 그친다.

(3) 불문법원의 중요성

- 행정 영역의 복잡성과 전문성으로 인해 성문법만으로 모든 사안을 규율하기 어렵고, 법률유보의 원칙에도 불구하고 행정 재량의 영역에서 행정법의 일반 원칙(조리)이 위법성 판단의 중요한 기준이 되는 등 불문 법원의 역할이 매우 크다.

4. 법원의 체계

- 행정법의 법원 체계는 헌법을 최상위 규범으로 하며, 법규범 간의 상하 관계에 따라 효력의 우열이 결정되는 피라미드 구조를 이룬다.

(1) 헌법(최상위)

- 행정조직 및 작용의 기본 원리와 국민의 기본권을 규정하는 최고 규범이다. 모든 행정작용은 헌법에 합치되어야 한다.

(2) 법률 및 국제법

- 국회가 제정한 법률과 헌법에 따라 체결·공포된 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규가 법률과 동일한 효력을 가진다.

(3) 명령

- 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등 행정기관이 제정한 법규명령으로서, 법률의 세부 사항을 규정하거나 위임받은 사항을 집행한다.

(4) 자치 법규(조례·규칙)

- 지방자치단체가 법령의 범위 내에서 제정하는 조례(의회 제정)와 규칙(단체장 제정)이 당해 자치단체의 영역 내에서 효력을 가진다.

(5) 불문 법원

- 행정관습법, 판례법, 조리 등은 성문 법원을 보충하거나 해석하는 기준으로 작용하며, 성문법이 없을 때 보충적으로 행정작용의 법원이 된다.

II. 행정법의 성문법원

1. 정의

- 법률이라는 성문(成文)의 형태로 존재하는 규범을 의미한다.

2. 헌법

- 행정법의 최고 법원으로서, 법률유보의 원칙, 법치주의, 민주주의 원리 등 행정의 기본 원리를 제공하며 국민의 기본권을 보장한다. 행정법의 모든 규범과 행정작용은 헌법에 합치되어야 한다.

3. 법률

- 국회의 의결을 거쳐 제정된 성문 법규범으로서, 행정조직, 행정작용에 대한 가장 중요한 직접적인 근거를 제공한다. 법률은 국민의 권리·의무에 관한 본질적인 사항을 규정하여 법률유보의 원칙을 실현한다.

4. 명령

- 행정기관이 법률의 위임을 받아 제정하거나 법률을 집행하기 위해 제정하는 법규명령을 의미한다. 대통령령(시행령), 총리령, 부령(시행규칙) 등이 있으며, 이들은 법률에 위반되어서는 안 된다.

5. 자치법규

- 지방자치단체가 제정하는 조례(지방의회 의결)와 규칙(지방자치단체장 제정)이 있다. 조례는 법령의 범위 내에서 제정되어 법규의 효력을 가지며, 규칙은 지방자치단체장의 권한에 속하는 사무에 관하여 제정된다.

6. 행정규칙

- 행정조직 내부에서 행정 사무의 처리 기준이나 운영 방침을 정하기 위해 제정하는 규범이다. 원칙적으로 대외적인 구속력을 가지지 않아 행정법의 법원은 아니지만, 재량 준칙이 반복되어 평등의 원칙이나 신뢰 보호의 원칙에 따라 대외적 구속력을 갖는 경우(자기 구속의 법리)에는 실질적 법원으로 기능하기도 한다.

7. 국제법(조약 및 일반적으로 승인된 국제법규)

(1) 헌법 제6조 제1항

- 대한민국 헌법은 헌법에 의하여 체결 · 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다고 규정한다. 따라서 이들은 국내 행정법에 대해 직접적인 구속력을 가지는 성문법원이 된다.

(2) 조약

- 국가 간에 체결된 문서에 의한 합의로서, 인권, 노동, 무역, 환경 등 다양한 분야에서 행정작용의 기준을 제시한다. 행정주체는 조약의 내용에 위반되는 행정작용을 할 수 없다.

(3) 일반적으로 승인된 국제법규

- 국제 관습법 등 국제 사회에서 국가들이 공통적으로 인정하는 법규범을 의미하며, 이 역시 국내 행정법의 법원으로 기능한다.

III 행정법의 불문법원

1. 정의

- 불문 법원은 성문(成文)의 형태로 존재하지 않지만 법적 확신을 얻어 행정주체의 행정작용을 구속하는 규범을 의미한다. 이는 성문법의 불완전성을 보충한다. 특히, 행정 재량권 행사의 통제 기준으로서 법치 행정의 실현에 중요한 역할을 한다.

2. 행정관습법

(1) 개념

- 행정 분야에서 오랜 기간에 걸쳐 반복적으로 형성된 관행에 대해 국민과 행정기관이 법적 구속력을 인정하고 있는 규범이다. 성립 요건으로는 관행의 존재와 법적 확신이 필요하다.

(2) 효력

- 행정관습법은 법률의 보충적 법원으로 기능한다. 행정관습법이 성문법에 위반되거나 모순될 경우 효력을 가질 수 없다(성문법우위 원칙). 다만, 성문법이 특정 사항을 관습에 위임한 경우에는 관습이 직접적 법원이 될 수 있다.

(3) 폐지된 관습법(폐지 관습)

- 기존의 관습이 새로운 법률이 제정됨에 따라 효력을 잃고 폐지된 관습으로 남는 경우가 있다. 판례는 특정 관습이 법적 효력을 가지는지 여부를 엄격하게 판단한다.

3. 판례법

(1) 개념 및 효력

- 판례법은 법원의 판결에 의해 법규범이 형성되는 것을 의미한다. 대륙법계에 속하는 한국은 판례가 원칙적으로 법원을 구성하지는 않으나, 상급법원(대법원)의 판례가 하급심에 사실상의 구속력을 가지며 법 해석의 통일을 통해 실질적인 법원으로서 역할을 한다.

(2) 행정소송의 기속력

- 행정소송법상 확정된 판결은 당해 사건에 관하여 당사자인 행정청과 관계 행정청을 기속하는 효력(기속력)을 가진다. 이는 특정 사건에 한정되지만, 실질적으로 유사 사건에 대한 행정청의 반복된 위법 행위를 막아 간접적으로 법원으로서 기능한다.

4. 조리(행정법의 일반원칙)

(1) 개념

- 조리(條理)란 사물의 본성 또는 합리적인 이치를 의미하며, 법률에 규정이 없을 때 보충적 법원으로서 기능하는 일반적인 행위 기준이다. 행정법에서는 조리가 행정법의 일반 원칙이라는 이름으로 구체화되어 가장 중요한 불문 법원으로 인정된다.

(2) 행정법의 일반원칙

- 조리는 다음과 같은 행정법의 일반 원칙을 통해 행정작용을 구속한다. 이 원칙들은 특히 행정청이 법률로부터 재량권을 부여받은 경우 재량권의 한계를 설정하는 통제 기준으로 활용된다.

① 비례의 원칙(과잉금지의 원칙)

- 행정목적 달성을 위해 사용되는 수단은 목적과 합리적인 비례 관계를 이루어야 하며, 목적 달성에 필요한 최소한에 그쳐야 한다는 원칙이다.

② 신뢰 보호의 원칙

- 행정청의 선행 행위(공적인 견해 표명)에 대한 국민의 정당한 신뢰는 보호되어야 하며, 행정청은 사정 변경이 없는 한 선행 행위에 반하는 행위를 해서는 안 된다는 원칙이다.

③ 평등의 원칙

- 합리적인 이유 없이 특정 개인을 차별해서는 안 된다는 원칙이다. 행정청이 재량 준칙을 반복하여 시행함으로써 스스로를 구속하게 되는 자기 구속의 법리는 평등의 원칙과 신뢰 보호의 원칙에서 그 근거를 찾는다.

④ 부당결부 금지의 원칙

- 행정주체가 공권력 행사와 상대방의 의무 이행 사이에 실질적인 관련성이 없는 부당한 결부를 통해서 상대방에게 반대급부를 강요하거나 부당한 제한을 가해서는 안 된다는 원칙이다.

⑤ 권한 남용 금지의 원칙

- 행정청이 법률에 의해 부여받은 권한을 정당한 목적이 아닌 부당한 동기로 사용하는 것을 금지하는 원칙이다.

IV. 결론

- 행정법의 법원은 성문법원(헌법, 법률, 명령, 자치법규, 행정규칙, 국제법)과 불문법원(행정관습법, 판례법, 조리)으로 구성되며, 법치 행정의 원리를 구현하는 규범적 근거이다. 헌법이 최고 법원이며 법률이 중심을 이루는 성문법원 중심주의 하에서도, 조리를 통해 구체화된 비례의 원칙, 평등의 원칙, 신뢰 보호의 원칙 등 행정법의 일반 원칙은 행정 재량권 통제의 핵심 기준으로서 불문 법원 중 가장 중요한 역할을 수행한다. 행정주체는 모든 행정작용에서 이러한 성문 및 불문 법원에 의해 구속된다.